

1527988-82.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1527988-82.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527988-82.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MASCARINI CANELLA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

FERNANDO MASCARINI CANELLA e GILMAR SILVA VERAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 10h16min, na Rua Robert Bosch, 469, Barra Funda, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante escalada, fios de energia, pertencentes à vítima, representada por C. S. A denúncia foi recebida, os réus foram citados e intimados e notificados e apresentaram resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, em sede de audiência de instrução, foram ouvidos o representante da vítima, dois policiais e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações finais, o Ministério Público buscou a parcial procedência da ação penal, pugnando pelo reconhecimento do crime em sua forma tentada e pelo afastamento da qualificadora referente à escalada.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela improcedência da ação penal, requerendo a absolvição dos réus com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta, por se tratar de local abandonado.

Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora da escalada, o reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com a agravante da reincidência, o reconhecimento da

modalidade tentada, com diminuição de pena no máximo legal estabelecido, bem como pela fixação do regime diverso do fechado, em face do disposto no art. 387, §2º do Código de Processo Penal, a gratuidade da justiça e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Sem dúvida que a absolvição à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Não há o que se falar em atipicidade da conduta. Isso porque, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, o local dos fatos não se trata de estabelecimento abandonado, apenas temporariamente desocupado, tanto que permanecia vigiado pelo próprio representante da empresa vítima.

Com efeito, a testemunha Carlos Soares, representante da vítima, relatou em juízo que fora contratado pela empresa vítima para vigiar o local, e no dia dos fatos após ouvir barulhos acionou a polícia que conseguiu prender os acusados.

De não bastasse isso, o abandono não pode ser presumido; é necessário se demonstrar a evidente vontade do proprietário em se desfazer do bem ou coisa, o que, conforme as provas colhidos, não restou minimamente comprovado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples e Perigo de desastre ferroviário em concurso formal - Sentença condenatória - Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, bem como pela atipicidade da conduta - Reconhecimento de coisa abandonada - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Condenação mantida - Penas e regime prisional bem dosados, ante a reincidência do réu -

RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500918-

87.2021.8.26.0617; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

13/01/2022; Data de Registro: 13/01/2022)

A autoria do crime também veio devidamente comprovada.

Isso porque, o depoimento do segurança do local em que os fatos se deram, vez, veio comprovado pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo e ainda pelas confissões dos réus.

Ouvidos em juízo, João Pedro Macedo de Souza e Onofre Monte Júnior, policiais militares e testemunhas, relataram que estavam em patrulhamento pelas imediações da Barra Funda, quando foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de furto. O solicitante era vigia do local e informou que dois indivíduos entraram no estabelecimento para furtarem fios. Ao chegarem ao local dos fatos avistaram os indivíduos em posse de faca e alicate, com fios cortados em mãos, colocando no interior de uma mochila. Afirmaram que o segurança do local teria dito que os acusados haviam estourado o cadeado e entrado pelo portão traseiro, deixando do lado de fora duas bicicletas. Indagados, os réus teriam confessado informalmente a prática delitiva. Por fim, os conduziram ao Distrito Policial.

Neste ponto, ressalta-se que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra os acusados. Ao contrário a narrativas dos dois policiais foi

devidamente confirmada pelo próprio autor do crime o que reforça ainda mais a posição adotada por esta magistrada e pela maioria esmagadora da doutrina e jurisprudência como se demonstra:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por fim, como acima apontado, interrogado em juízo, o réu Fernando Mascarini Canella, afirmou que estava passando pelo local na companhia de Gilmar e ao se depararem com o portão entreaberto resolveram entrar para usar drogas. Após usarem drogas ambos visualizaram alguns fios soltos e outros pendurados e resolveram subtraí-los. E no momento em que puxavam os fios e os colocavam em sua camisa, foram surpreendidos pela polícia e de pronto confessaram a prática do furto. No mesmo sentido, Gilmar Silva Veras também confessou os fatos disposto na denúncia, em seu interrogatório judicial. Relatou que estava passando com o corréu Fernando pelo local e ao avistarem o portão aberto, resolveram entrar para fazerem uso de entorpecentes. Já no local decidiram furtar alguns fios elétricos, colocando-os em sua camisa. Na saída, foram abordados por policiais que os conduziram ao Distrito Policial.

A materialidade delitativa também veio devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição/apreensão/entrega dos fios subtraídos, relatório final da autoridade policial, tudo aliado a firme e segura prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório.

O concurso de pessoas, também restou comprovado nos autos, notadamente pelos relatos das testemunhas e ainda da confissão dos réus que afirmaram que em conjunto, resolveram subtrair os fios que estavam no local.

Já no que toca à qualificadora da escalada, como bem pontuado por ambas as partes, essa não se restou comprovada no bojo dos autos.

Com efeito, os peritos afirmaram que o ingresso se deu provavelmente por ESCALADA e DESTRUIÇÃO da concertina metálica, além de ROMPIMENTO do cadeado que guarnecia o portão.

No entanto, não há como se presumir que os réus romperam o cadeado ou ainda escalaram o muro para ingressarem no local, já que o segurança que ali estava nada disse a este respeito e ainda afirmou que o imóvel estava já danificado, antes dos fatos, o que enfraquece a prova produzida.

Por fim, cabe aqui ressaltar que o furto foi tentado, como muito bem ponderado por ambas as partes já que o crime não se consumou em razão dos acusados terem sido surpreendidos por policiais enquanto ainda retiravam os fios do estabelecimento vítima, para serem por eles subtraídos. Tal fato foi devidamente comprovado pelos depoimentos colhidos nos autos.

Caracterizada, portanto, a infração penal de furto qualificado tentado, passo a dosimetria da pena.

Do réu Fernando Mascarini Canella:

O réu é triplamente reincidente, inclusive específico, de acordo com a certidão de fls. 77/82, tendo em vista que foi condenado definitivamente pelo delito de furto qualificado, por três vezes, perante a 18ª Vara Criminal (Autos nº 0110210-80.2014.8.26.0050), a 22ª Vara Criminal (Autos nº 0054718-30.2019.8.26.0050) e na 7ª Vara Criminal (Autos nº 1509975-69.2020.8.26.0228) todos do Foro Criminal Central, fatos estes que serão apreciados na segunda fase da dosimetria. Ademais, há de se considerar os maus antecedentes criminais e a personalidade voltada para o crime do acusado, pois, foi condenado definitivamente por mais cinco oportunidades (Autos nº 0012984-61.2003.8.26.0050 perante a 23ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0021083-49.2005.8.26.0050 a 4ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0060446-24.1997.8.26.0050 a 8ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0025984-02.2001.8.26.0050 a 14ª Vara Criminal de São Paulo (Exec nº 03 - fls. 71) e Autos nº 0027318-13.1997.8.26.0050 a 27ª Criminal de São Paulo - Exec. nº 01 - fls. 70).

Assim, não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do

Código Penal, devendo a pena base ser aumentada em 1/2, chegando ao patamar de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa.

E nesse ponto, não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e doutrina:

STJ- “condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes” (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, “não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência” (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

“Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, há de se considerar a tripla reincidência citada anteriormente, assim sendo a pena deve ser agravada em mais 1/4, chegando-se a 03 anos, 09 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Presente também ao caso a atenuante da confissão, além disso, deve-se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Neste ponto, para essa magistrada, respeitadas posições em contrário, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: “(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial,

não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020: "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

STF: "Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que

acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade" (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo AranhaFilho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

A pena, contudo, não deve ser alterada, já que neste caso atenuante e agravante se compensam.

Na terceira fase, deve reconhecida a modalidade tentada, como ponderado pelas partes. Assim sendo, considerando o iter criminis percorrido pelos acusado que juntamente com seu comparsa, já haviam cortado os fios e os colocados dentro da camisa, e não conseguiram sair do local pois foram surpreendidos com a chegada da polícia, a pena deve ser diminuída pela metade, totalizando 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 09 dias-multa.

Do réu Gilmar Silva Veras:

O réu é multirreincidente, inclusive específico, de acordo com a certidão de fls. 83/91, tendo em vista que foi condenado definitivamente por nove vezes, entretanto, apenas seis condenações são capazes de caracterizar a reincidência (Autos nº 0094023-55.2018.8.26.0050 da 19ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 1509975-69.2020.8.26.0228 da 7ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0096373-50.2017.8.26.0050 da 7ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0009824-42.2014.8.26.0050 da 12ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0018159-45.2017.8.26.0050 da 27ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0012047-51.2017.8.26.0635 da 17ª Vara Criminal de São Paulo), visto que as outras três tiveram sua extinção pelo cumprimento a mais de cinco anos (Autos nº 0008961-28.2010.8.26.0050 da 21ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0011779-84.2009.8.26.0050 da 31ª Vara Criminal de São Paulo, Autos nº 0086460-11.1998.8.26.0050 da 26ª Vara Criminal de São Paulo).

Assim sendo, considerando o acima fundamentado, em razão das três condenações já extintas, a pena base deve ser aumentada em 1/4, perfazendo 2 anos, 6 meses de reclusão e 12 dias-multa

Na segunda fase, considerando as 06 reincidências, acima apontadas a pena será aumentada em 2/3, chegando a 4 anos, 2 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Também com relação a este corréu deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, inc.II, alínea "j", pelos motivos acima já expostos e a atenuante da confissão, e, portanto, a pena deve se manter inalterada.

Na terceira fase, deve reconhecida a modalidade tentada e considerando o iter criminis praticado pelos acusados como verificado, a pena deve ser diminuída pela metade, chegando a 02 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa .

No mais, considerando que não há nos autos provas da condição financeira dos acusados, fixa-se o dia multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar ambos os réus como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, combinado com art. 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-se, assim, ao réu FERNANDO MASCARINI CANELLA a pena de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, e 09 dias-multa, no mínimo legal e ao réu GILMAR SILVA VERAS a pena de 02 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, notadamente em razão da multirreincidência específica e dos maus antecedentes atestados nos autos de ambos os acusados.

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

Nesse sentido:

"Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (STJ, AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, Dje 11/06/2019).

Ainda, os motivos que foram levados em conta para a fixação da pena e ainda o regime fechado para início de cumprimento, não favorecem os acusados, pois já foram condenados por outros crimes contra o patrimônio e mesmo assim novamente se puseram a delinquir, demonstrando que os réus não fazem jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Como é sabido, não basta que os acusados satisfaçam os requisitos objetivos da lei para ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, é necessário, também que os requisitos subjetivos lhes sejam favoráveis. Nesse sentido, a jurisprudência: "Eventual substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação de regime prisional, estão a depender da análise articulada das circunstâncias subjetivas dos pacientes, as quais, in casu, foram inteiramente desfavoráveis".

Deixo de computar o período de prisão provisória dos réus para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente em critério objetivo. Depende, também, do mérito do condenado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos parte da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Além disso, prevalecer o entendimento de que a lei não determina o cômputo do período de prisão provisória como meio de antecipar a progressão de regime, mas como critério para fixar o regime inicial de cumprimento da pena, aquele que sob custódia esteve no curso do processo poderá ser agraciado com progressão, na fase de execução criminal, com novo desconto do período já considerado para beneficiá-lo com regime menos gravoso na sentença condenatória.

Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2º do CPP, a teor do que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.

O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2º do Código Penal.

No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2º. e 3º do Código Penal.

É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime.

A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que inclui o regime, de maneira correta." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 805/806).

Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP." (AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, Dje 03/06/2019).

"HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)".(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 10/04/2019).

Ademais, em razão de estarem respondendo ao processo presos, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou. Assim, não poderão recorrer desta sentença em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar dos acusados que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, aditando-se a provisória se o caso, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.
Intime-se a vítima, consoante determinação legal.
Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.
Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.
P.R.I.C.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA